

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2737/2532

บริษัท เอฟ. แอล. สมิตท์ จำกัด
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.รฎีกา มาตรา 76 ทวิ

ป. รฎีกา มาตรา 76 ทวิ ซึ่งกำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศเยี่ยงโจทก์เสียภาษีเงินได้เฉพาะที่เกี่ยวกับเงินได้หรือ ผลกำไรในประเทศไทยนั้น เงินได้หรือผลกำไรดังกล่าวหมายถึงเงินได้หรือผลกำไรที่ได้รับตามความเป็นจริง ไม่มีบทบัญญัติใดให้อำนาจเจ้าพนักงานประเมินใช้อัตรากำไรสุทธิของนิติบุคคลอื่นมาเป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวณกำไรสุทธิของโจทก์ได้ ตรงกันข้ามใน มาตรา 76 ทวิ วรรคสองนั่นเองเป็นบทบัญญัติที่เป็นทางแก้สำหรับกรณีที่ไม่สามารถคำนวณกำไรสุทธิได้ตามวรรคแรก โดยกฎหมายให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการประเมินภาษีตามมาตรา 71(1) มาใช้บังคับ คือให้เจ้าพนักงานประเมินทำการประเมินภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของยอด รายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานประเมินทำการประเมินโดยใช้อัตรากำไรสุทธิ 21.87เปอร์เซ็นต์ ของนิติบุคคลมาเป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวณหากำไรสุทธิของโจทก์จึงเป็นการไม่ชอบ.

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ อ้างว่าโจทก์ไม่มีสถานประกอบการถาวรอยู่ในประเทศไทย โจทก์จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามอนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งประเทศไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศเดนมาร์ก เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้และจากทุนข้อ 7 และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2505 มาตรา 3 นอกจากนี้วิธีคำนวณภาษีของเจ้าพนักงานประเมินก็ไม่ถูกต้อง

จำเลยให้การว่า การประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ชอบแล้ว

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาเพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์โดยให้โจทก์เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปีพ.ศ. 2521-2523 ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 76 ทวิ โดยประเมินตามมาตรา 71(1) และตามประมวลรัษฎากร มาตรา 70 ทวิ โดยประเมินตามวิธีคำนวณกำไรย้อนกลับ กับเงินเพิ่มตามมาตรา 26 โดยให้โจทก์เสียในอัตราร้อยละ 30 ของเงินเพิ่มตามกฎหมาย คำขอของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ทางพิจารณาโจทก์นำสืบว่าโจทก์ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2521 - 2523 จากเจ้าพนักงานประเมินรวม 6 ฉบับ ซึ่งประเมินให้โจทก์เสียภาษีตามมาตรา 70 ทวิ และ 76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร รวมเป็นเงินค่าภาษีและเงินเพิ่มทั้งหมดจำนวน 13,192,854.93 บาท ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.3 - จ.8 โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณ์ได้มีคำวินิจฉัยให้ยกคำอุทธรณ์ของโจทก์ โดยยืนตามการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน แต่ให้ลดจำนวนภาษีและเงินเพิ่มลง คงให้โจทก์เสียรวมเป็นเงินจำนวน 6,379,506.56 บาท ตามเอกสารหมายเลข 10 - จ.15 โจทก์เห็นว่าการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของจำเลยไม่ถูกต้องเพราะโจทก์ได้รับการยกเว้น ภาษีตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง แห่งอนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งประเทศไทย กับรัฐบาลแห่งประเทศเดนมาร์ก เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนฯ ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 19 และตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2505 โจทก์ส่งลูกจ้างเข้ามาในประเทศไทยตามสัญญาซื้อขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตซีเมนต์ระหว่างโจทก์กับบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด ก็เพียงให้ความช่วยเหลือแนะนำการติดตั้งเครื่องจักรแก่พนักงานของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด โจทก์ไม่ได้เข้ามาดำเนินการตามโครงการก่อสร้าง ติดตั้ง หรือประกอบหรือโครงการอื่นทำนองเดียวกัน การก่อสร้าง ติดตั้ง หรือประกอบเครื่องจักรทั้งหมดตามสัญญานั้น บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด เป็นผู้ควบคุมและติดตั้งเครื่องจักรเองโดยบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด ได้ว่าจ้างผู้รับเหมา 4 ราย เป็นผู้ดำเนินการ ขณะที่ผู้รับเหมาดำเนินการตามโครงการนายวิสุทธิ อนุพันธ์เมธา พนักงานซึ่งเป็นวิศวกรของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด ได้เป็นผู้ควบคุมการประกอบ ติดตั้ง หากมีปัญหาใดผู้รับเหมาจะสอบถามนายวิสุทธิโดยไม่ได้ขอความเห็นจากพนักงานของโจทก์ที่ส่งมาให้ แต่ถ้าหากนายวิสุทธิไม่สามารถเข้าใจชัดเจนนายวิสุทธิจึงจะขอคำแนะนำจากพนักงานของโจทก์ดังนั้นย่อมถือไม่ได้ว่าโจทก์มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทยตามอนุสัญญาดังกล่าวข้อ 5 วรรคสี่ โจทก์จึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีตามข้อ 7 วรรคหนึ่งแห่งอนุสัญญานั้น ประกอบด้วยมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2505 การที่เจ้าพนักงานประเมินและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์นำเอาอัตรา

กำไรสุทธิของโจทก์ที่ได้รับจากการดำเนินการควบคุมการติดตั้งและเดินเครื่องจักรให้แก่บริษัทปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด มาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณหากำไรสุทธิ แล้วประเมินเรียกเก็บภาษีจากโจทก์ในคดีนี้นั้นโจทก์เห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เนื่องจากประมวลรัษฎากร มาตรา 76 ทวิ วรรคสองบัญญัติไว้ว่า เมื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่สามารถจะคำนวณหากำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีตามปกติได้แล้ว ก็ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการประเมินภาษีตามมาตรา 71 (1) มาใช้บังคับโดยอนุโลม ดังนั้นการที่เจ้าพนักงานประเมินและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อ้างว่าโจทก์ไม่สามารถนำงบกำไรขาดทุนและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ กรณีจึงเข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา 76 ทวิวรรคสอง ดังกล่าวแล้วโจทก์จึงมีหน้าที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับหรือยอดขายก่อนหักรายจ่ายใด ๆ จะนำวิธีประเมินอย่างอื่นมาใช้ไม่ได้ ส่วนที่เจ้าพนักงานประเมินและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อ้างว่า เงินได้ของโจทก์จากการให้บริการการควบคุมติดตั้งและเดินเครื่องจักรให้แก่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด เป็นเงินได้ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร ภาษีต่าง ๆ ตามสัญญาที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด ออกแทนให้โจทก์ จึงเป็นประโยชน์เพิ่มที่จะต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้ของโจทก์เพื่อเสียภาษีด้วยนั้น โจทก์เห็นว่าเงินภาษีที่ถือว่าเป็นประโยชน์ใด ๆ ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 39 หรือมาตรา 40 (2) ซึ่งถือว่าเป็นเงินได้อันจะนำมาคำนวณภาษีด้วยนั้นต้องเป็นประโยชน์ที่ได้รับมาแล้วมิใช่เพียงมีสิทธิที่จะได้รับในอนาคต เมื่อบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด ยังไม่ได้ชำระภาษีใด ๆ ให้แก่จำเลยแทนโจทก์เนื่องจากยังเป็นคดีกันอยู่ เจ้าพนักงานของจำเลยจึงไม่มีสิทธิจะนำจำนวนค่าภาษีที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด รับว่าจะชำระแทนโจทก์ให้มารวมคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษี ดังนั้นจำนวนค่าภาษีที่โจทก์จะต้องเสียในอัตรา ร้อยละ 5 ของยอดรายรับจำนวน 1,200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ 24,598,882.37 บาท จะเป็นเงินทั้งหมด 1,229,944.10 บาท นอกจากนี้เงินได้ที่โจทก์ได้รับจากการช่วยเหลือควบคุมการก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักรให้กับบริษัทปูนซิ

เมนต์ไทยจำกัด เมื่อโจทก์ได้จำหน่ายเงินจำนวนนี้ออกไปจากประเทศไทย จำต้องเสียภาษีตามมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร นั้น ปรากฏว่าเงินได้จำนวนดังกล่าวยังไม่ได้หักรายจ่ายใด ๆ จึงถือไม่ได้ว่าเป็นเงินกำไรหรือเงินประเภทอื่นใดที่กันไว้จากกำไรหรือที่ถือได้ว่าเป็นกำไรซึ่งหากโจทก์จะต้องเสียภาษีดังกล่าวแล้ว เจ้าพนักงานของจำเลยก็ต้องใช้วิธีการคำนวณหากำไรสุทธิในการจำหน่ายเงินกำไรของโจทก์ โดยการเทียบกลับจากรายรับว่า ถ้าจำนวนภาษีที่จะชำระในอัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับจะเป็นเงินกำไรสุทธิเท่าใด ซึ่งเมื่อคำนวณแล้วจะเป็นจำนวนค่าภาษีที่โจทก์จะต้องชำระตามมาตรา 70 ทวิ เพียง 702,825.20บาท

จำเลยนำสืบว่า กองภาษีเงินได้นิติบุคคลของจำเลยสืบทราบมาว่าโจทก์ได้ทำสัญญาซื้อขายและติดตั้งเครื่องจักรพร้อมกับอุปกรณ์ในการผลิตซีเมนต์กับบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด และบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด สัญญาที่โจทก์ทำกับบริษัททั้งสองมีลักษณะคล้ายคลึงกัน และทำในปี พ.ศ. 2521 ซึ่งเป็นปีเดียวกัน ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 6 และ 10 ตามลำดับ จึงได้ออกหมายเรียก 2 ฉบับถึงโจทก์ให้โจทก์จัดส่งสัญญาทั้ง 2 ฉบับ มาให้ทำการตรวจสอบโจทก์ได้มอบอำนาจให้ตัวแทนมาพบและส่งมอบสัญญาทั้งสองฉบับให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบของจำเลย ต่อมาได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับภาษีอากรของจำเลยพิจารณา ซึ่งที่ประชุมมีมติว่าการซื้อขายเครื่องจักรตามสัญญาดังกล่าวของโจทก์กับบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด และบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด นั้น ไม่ได้กระทำผ่านสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย จึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีตามอนุสัญญาเพื่อการเว้นเก็บภาษีซ้อนฯ ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเดนมาร์ก ข้อ 7 วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา 3 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2505 แต่เงินค่าช่วยเหลือดูแลการติดตั้งและเดินเครื่องจักรจำนวน 1,200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ 24,598,882.37 บาท ที่โจทก์ได้รับจากบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด เข้าลักษณะเป็นกำไรจากธุรกิจจะต้องเสียภาษีตาม

มาตรา 76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากโจทก์ได้จัดส่งลูกจ้างจำนวน 24 คน เข้ามาในประเทศไทยเพื่อให้คำแนะนำในการติดตั้งเครื่องจักรเป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปี การให้บริการดังกล่าวของโจทก์จึงเข้าลักษณะเป็นการดำเนินการตามโครงการ ก่อสร้างติดตั้งหรือประกอบหรือโครงการอื่นทำนองเดียวกัน อันถือได้ว่าโจทก์มีสถาน ประกอบการถาวรที่ตั้งในประเทศไทยตามข้อ 5 วรรคสี่ (ก) แห่งอนุสัญญาดังกล่าว เงินได้จำนวนนั้นจึงอยู่ในบังคับที่จะต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศไทยตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง แห่งอนุสัญญาดังกล่าวเจ้าพนักงานประเมินจึงได้ทำการประเมินเรียกเก็บ ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากโจทก์ตามสัญญาที่โจทก์ทำกับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด และบริษัทปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด ตามมาตรา 76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ปราบกฏตามสัญญาว่า ค่าภาษีต่าง ๆ นั้น บริษัททั้งสองเป็นผู้ชำระแทนให้โจทก์ เจ้า พนักงานประเมินจึงนำค่าภาษีดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นรายได้ด้วย และโจทก์ยัง ต้องเสียภาษีตามมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากกำไรที่เกิดจากการ ให้บริการในการติดตั้งเครื่องจักรตามสัญญานั้นถือเป็นผลกำไรที่เกิดในประเทศไทย โจทก์จึงมีหน้าที่เสียภาษีเมื่อโจทก์จำหน่ายกำไรดังกล่าวออกไปจากประเทศไทย รวมทั้งเงินเพิ่มตามมาตรา 26 แห่งประมวลรัษฎากรบริษัทปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด ได้ชำระค่าภาษีดังกล่าวแทนโจทก์ให้แก่เจ้าเลยแล้วส่วนบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด ยังไม่ชำระให้และเมื่อเจ้าพนักงานประเมินได้ขอให้โจทก์จัดส่งบัญชีงบกำไร ขาดทุนและหลักฐานเอกสารอื่น ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานในส่วนที่เป็นรายได้จาก บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด โจทก์ก็ไม่ยอมส่งมาให้เจ้าพนักงานประเมินจึงใช้อัตรา กำไรสุทธิเฉลี่ยจำนวน 21.87เปอร์เซ็นต์ ของโจทก์ที่ได้รับจากการบริการติดตั้ง เครื่องจักรให้แก่บริษัทปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด มาเป็นเกณฑ์คำนวณยอดกำไร สุทธิตามมาตรา 24 แห่งประมวลรัษฎากร เพื่อให้โจทก์เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก รายได้ที่โจทก์ได้รับจากบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัดสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2521-2523 เป็นเงินค่าภาษีและเงินเพิ่มตามประมวลรัษฎากรมาตรา 70 ทวิ

จำนวน 4,034,831.67 บาทและตามมาตรา 76 ทวิ จำนวน 9,158,023.26 บาท รวมเป็นเงิน13,192,854.93 บาท โจทก์ได้อุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ต่อมาคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้มีคำวินิจฉัยว่าการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินชอบแล้ว แต่ให้ลดจำนวนภาษีและเงินเพิ่มลงคงให้โจทก์เสียเป็นเงินจำนวน 6,379,506.56 บาท

พิเคราะห์แล้ว ปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยมีเพียงว่าเจ้าพนักงานประเมินจะใช้อัตรากำไรสุทธิ 21.87 เปอร์เซนต์ ของโจทก์ที่ได้รับจากการให้บริการในการติดตั้งเครื่องจักรที่บริษัทปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด มาเป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวณหากำไรสุทธิสำหรับเงินได้ที่โจทก์ได้รับจากบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด ได้หรือไม่ และเงินค่าภาษีที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด รับจะออกแทนให้โจทก์ตามสัญญานั้น จะต้องนำมารวมคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีเงินได้เสียทีเดียวหรือไม่ ในปัญหาแรกจำเลยอุทธรณ์ว่า โจทก์ทำสัญญากับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด และกับบริษัทปูนซิเมนต์นครหลวงจำกัด มีลักษณะเหมือนกัน ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน แต่ในรายบริษัทปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด สามารถคำนวณหากำไรสุทธิได้ คืออัตรากำไร21.87 เปอร์เซนต์แต่ในรายบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด โจทก์ มีเจตนาหลีกเลี่ยงไม่นำเสนอกำไรขาดทุน เพื่อจะได้เสียภาษีตามประมวลรัษฎากรมาตรา 71 (1) ซึ่งเป็นจำนวนเงินต่ำกว่า 21.87 เปอร์เซนต์ ทำให้ไม่เป็นธรรม เจ้าพนักงานประเมินจึงมีอำนาจใช้อัตรากำไรสุทธิ 21.87เปอร์เซนต์ดังกล่าว มาเป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวณกำไรสุทธิของโจทก์ข้อเท็จจริงได้ความจากคำเบิกความของนายวิสุทธิอนุพันธ์เมธา พยานโจทก์ว่า โครงการติดตั้งและประกอบเครื่องจักรของบริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัด มีเครื่องจักรขนาดกำลังผลิต 4,000 ตันต่อวันเป็นจำนวนมากและต้องทำการติดตั้งหลายแห่ง และจะเหมือนกับโครงการดังกล่าวของบริษัทปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด หรือไม่ พยานไม่ทราบและจากพยานหลักฐานของฝ่ายจำเลยก็ไม่ได้ความว่า จำนวนเครื่องจักร กำลังของเครื่องจักรตลอดจนสถานที่ติดตั้งในโครงการ

ของบริษัทปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัดมากหรือน้อยใกล้เคียงกับของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด เพียงใด ซึ่งรายละเอียดในเรื่องเหล่านี้ย่อมเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงรายรับและรายจ่ายของโจทก์อันจะมีผลถึงการคำนวณหากำไรสุทธิดังนั้น จึงไม่สามารถที่จะเอากำไรสุทธิที่โจทก์ได้รับจากการทำสัญญากับบริษัทปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด ในอัตรา 21.87 เปอร์เซนต์ มาเป็นหลักเกณฑ์ในการหากำไรสุทธิในคดีนี้ได้อีกประการหนึ่งตามประมวลรัษฎากร มาตรา 76 ทวิ ซึ่งกำหนดให้นิติบุคคลเยี่ยงโจทก์เสียภาษีตามบทบัญญัติในส่วน 3 ของหมวด 3 เรื่องภาษีเงินได้ในส่วนที่เก็บจากบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เฉพาะที่เกี่ยวกับเงินได้หรือผลกำไรในประเทศไทย ซึ่งย่อมหมายความว่าถึงจำนวนเงินได้หรือผลกำไรที่โจทก์ได้รับตามความเป็นจริง ไม่มีบทบัญญัติใดที่ให้อำนาจเจ้าพนักงานประเมินใช้อัตรากำไรสุทธิของนิติบุคคลอื่นมาเป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวณหากำไรสุทธิของโจทก์ได้ ตรงกันข้ามในมาตรา 76 ทวิวรรคสองนั่นเอง เป็นบทบัญญัติที่เป็นทางแก้สำหรับในกรณีที่ไม่สามารถคำนวณกำไรสุทธิได้ตามวรรคแรก โดยกฎหมายให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการประเมินภาษีตามมาตรา 71 (1) มาใช้บังคับ กล่าวโดยสรุปคือ เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ เป็นบทบัญญัติที่กำหนดไว้ชัดแจ้งแล้วเช่นนี้ การที่เจ้าพนักงานประเมินทำการประเมินโดยใช้อัตรากำไรสุทธิ 21.87 เปอร์เซนต์ มาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวณหากำไรสุทธิของโจทก์ในคดีนี้ จึงเป็นการไม่ชอบ

ในปัญหาที่ว่า เงินค่าภาษีที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด รับจะออกแทนให้โจทก์ตามสัญญานั้น จำเลยอุทธรณ์ว่าค่าภาษีดังกล่าวจะต้องนำมารวมคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีเสียทีเดียว ศาลฎีกาเห็นว่าเงินที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด จะออกให้เป็นค่าภาษีเงินได้ของโจทก์นั้น ก็จะต้องทราบเสียก่อนว่าโจทก์มีกำไรสุทธิเท่าใดจะต้องเสียภาษีเงินได้เท่าใด และภาษีเงินได้ที่โจทก์จะต้องเสียจำนวนนี้เมื่อบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด ออกให้แทน โจทก์จึงชอบที่จะนำมารวมกับรายได้อันแท้จริงของ

โจทก์ แต่ข้อเท็จจริงในคดีนี้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด ยังมีได้ออกเงินค่าภาษีให้โจทก์แต่อย่างใด จึงถือไม่ได้ว่าเป็นเงินได้พึงประเมินตามที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร มาตรา 39 ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานประเมินนำค่าภาษีที่โจทก์จะได้รับจากบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด มาคำนวณเป็นเงินได้เพื่อให้โจทก์เสียภาษีนั้นจึงไม่ชอบที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษามานั้นชอบแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้นทุกข้อ"

พิพากษายืน

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตรต์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ประมวลรัษฎากรได้บัญญัติแบ่งออกเป็นลักษณะ เป็นหมวด และเป็นส่วนลดหลั่นกันตามลำดับ เช่น ลักษณะ 2 ว่าด้วยภาษีอากรฝ่ายสรรพากรในลักษณะนี้แบ่งออกเป็นหลายหมวด เช่น หมวด 1 ว่าด้วยบทเบ็ดเสร็จทั่วไป หมวด 2 ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากรประเมิน หมวด 3 ว่าด้วยภาษีเงินได้ หมวด 4 ว่าด้วยภาษีการค้า เป็นต้น การปรับใช้ประมวลรัษฎากรจึงต้องพิจารณาเนื้อหาในหมวดต่าง ๆ ว่ามีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันอย่างไร เช่น เนื้อหาในหมวด 1 ว่าด้วยบทเบ็ดเสร็จทั่วไป หรือเรียกกันว่าบทบัญญัติทั่วไปย่อมนำไปใช้ในหมวดอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันได้ แต่ถ้าไม่ใช้บทบัญญัติทั่วไปย่อมจะนำไปใช้ในหมวดอื่น ๆ ไม่ได้ เว้นแต่ในหมวดนั้น ๆ เองจะมี

ข้อบัญญัติให้นำไปใช้ในหมวดอื่นด้วย จึงนำไปใช้ได้ ดังเช่น หมวด 2 ว่าด้วยวิธีการ
เกี่ยวแกภาษีอากรประเมิน ซึ่งมีข้อกำหนดให้นำบทบัญญัติในหมวดนี้ไปใช้ในหมวด
อื่น ๆ ด้วย ดังมีถ้อยคำใน มาตรา 15 บัญญัติว่า "เว้นแต่จะมีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
ในหมวดต่าง ๆ แห่งลักษณะนี้ ให้ใช้บทบัญญัติในหมวดนี้บังคับแก่การภาษีอากร
ประเมินทุกประเภท" หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งในเรื่องเกี่ยวกับอากรประเมินทุกประเภท
ถ้ากฎหมายมิได้กำหนดวิธีการประเมินไว้เป็นพิเศษโดยเฉพาะแล้วจะต้องนำวิธีการ
ประเมินในส่วนนี้ไปบังคับใช้ เฉพาะในหมวด 2 นี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วน 1 ว่า
ด้วยการยื่นรายการและการเสียภาษีอากร ส่วน 2 ว่าด้วยการอุทธรณ์ และส่วน 3 ว่า
ด้วยบทกำหนดโทษ ทั้งสามส่วนในหมวดนี้จึงถือเป็นบทบัญญัติทั่วไปนำไปใช้ใน
หมวดอื่น ๆ ได้ด้วย เว้นแต่ในหมวดนั้น ๆ จะได้มีบทบัญญัติเป็นพิเศษโดยเฉพาะซึ่ง
แตกต่างไปจากบทบัญญัติทั่วไปก็จะนำบทบัญญัติในหมวด 2 ดังกล่าวไปใช้บังคับไม่
ได้เช่น เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินภาษีอากรโดยเจ้าพนักงานตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 18, 18 ทวิ, 20, 21 และ 24, 25 ในส่วน 1 ของหมวด 2 อันถือเป็น
หลักทั่วไปย่อมนำไปใช้ในส่วน 2 ว่าด้วยการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และส่วน
3 ว่าด้วยการเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล ของหมวด 3 ได้ เว้นแต่เฉพาะมาตรา 49, 60
ทวิ ในส่วนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และมาตรา 71 ในส่วนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้
กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินไว้เป็นพิเศษต่างหากจากหลักทั่วไปในหมวด 2 ดัง
กล่าว หากมีกรณีที่ต้องประเมินภาษีอากรตามบทมาตราพิเศษดังกล่าวก็ต้องบังคับไป
ตามนั้น ข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่บันทึกหมายเหตุนี้ เป็นกรณีที่โจทก์เป็น
บริษัทต่างประเทศ จัดส่งลูกจ้างจำนวน 24 คน เข้ามาในประเทศไทยเพื่อให้คำ
แนะนำในการติดตั้งเครื่องจักรเป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปี ให้แก่บริษัทปูนซิเมนต์
ไทย จำกัด โดยได้รับค่าช่วยเหลือดูแลการติดตั้งและเดินเครื่องจักรเป็นจำนวนเงิน
1,200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา การให้บริการของโจทก์ดังกล่าวจึงเข้าลักษณะ
เป็นการดำเนินการตามโครงการก่อสร้าง ติดตั้ง หรือประกอบ หรือโครงการอื่น

ทำนองเดียวกัน ในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งนั้นเป็นเวลาเกินกว่าสามเดือน อันถือได้
ว่าโจทก์มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย ตามข้อ 5 วรรคสี่ (ก) แห่ง
อนุสัญญา เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากรในส่วนที่
เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้และจากทุนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเดนมาร์ก
พ.ศ. 2508 เงินที่โจทก์ได้รับจากบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด จึงเข้าลักษณะเป็นเงิน
ได้หรือผลกำไรที่โจทก์ต้องยื่นรายการและเสียภาษีให้แก่รัฐบาลไทย ตามมาตรา 76
ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยคำนวณการเสียภาษีจากกำไรสุทธิตามหลักเกณฑ์
ทั่วไปในการคำนวณกำไรสุทธิของนิติบุคคลส่วน 3 หมวด 3 แห่งลักษณะ 2 แต่ถ้าไม่
สามารถคำนวณกำไรสุทธิได้หรือไม่ยื่นรายการซึ่งจำเป็นต้องยื่นตามมาตรา 76 ทวิ
วรรคสอง ได้กำหนดทางแก้ไขแล้ว โดยให้ประเมินภาษีตามวิธีการที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 71(1) ซึ่งเป็นบทบัญญัติพิเศษให้บริษัทต่างประเทศที่ไม่ยื่นรายการซึ่งจำเป็น
ต้องใช้ในการคำนวณภาษีหรือมิได้ทำบัญชีหรือไม่ครบตามที่กำหนดไว้ในมาตรา
17 และมาตรา 68 ทวิ หรือไม่นำบัญชีเอกสารหรือหลักฐานอื่นมาให้เจ้าพนักงาน
ประเมินทำการไต่สวนตามมาตรา 19 หรือมาตรา 23 เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจ
ประเมินภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับหรือยอดขายก่อนหักรายจ่ายใด ๆ
ของรอบระยะเวลาบัญชีแล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า ถ้ายอดรายรับหรือยอดขายก่อน
หักรายจ่ายดังกล่าวไม่ปรากฏ เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินโดยอาศัยเทียบ
เคียงกับยอดในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนนั้นขึ้นไป ถ้ายอดในรอบระยะเวลาบัญชีก่อน
ไม่ปรากฏให้ประเมินได้ตามที่เห็นสมควรจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้กำหนดแนวทางใน
การประเมินภาษีอากรของบริษัทต่างประเทศไว้เป็นขั้นเป็นตอน จากวิธี ที่ยากไปสู่
วิธีที่ง่ายเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการจัดเก็บภาษี เพราะบริษัทต่างประเทศไม่มี
ที่ทำการถาวรในประเทศไทยเป็นการยากที่จะทำการตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ได้
กฎหมายจึงตัดบทความยุ่งยากทั้งหลายเสีย ผู้บันทึกเห็นว่ากฎหมายคงไม่มี
เจตนารมณ์ที่จะทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากกลับจะไร้ผลไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้

เต็มเม็ดเต็มหน่วยขั้นตอนในการใช้กฎหมายในส่วนนี้ควรพิจารณาตามลำดับดังนี้
ขั้นตอนที่หนึ่ง คัดค้านวณภาษีจากกำไรสุทธิซึ่งเป็นวิธีการที่มีความยุ่งยากสลับซับซ้อน
ขั้นตอนที่สอง ถ้าไม่สามารถคัดค้านกำไรสุทธิได้ หรือไม่ยื่นรายการเสียภาษี
หรือยื่นรายการไม่ครบถ้วนสำนักงานประเมินมีอำนาจประเมินภาษีในอัตราร้อยละ 5
ของยอดรายรับหรือยอดขายก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ขั้นตอนที่สาม ถ้ายอดรายรับหรือ
ยอดขายไม่ปรากฏ กฎหมายกำหนดให้สำนักงานประเมินมีอำนาจประเมินภาษี
อากรโดยอาศัยเทียบเคียงกับยอดในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนนั้นขึ้นไป ขั้นตอนที่สี่
ถ้ายอดในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนก็ไม่ปรากฏ กฎหมายกำหนดให้สำนักงาน
ประเมินมีอำนาจประเมินภาษีอากรตามที่เห็นสมควร ซึ่งเป็นมาตรการสุดท้ายในการ
ประเมินเก็บภาษีของบริษัทต่างประเทศ และเป็นการให้อำนาจแก่สำนักงาน
ประเมินใช้ดุลพินิจอย่างกว้างขวาง ข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่บันทึก
หมายเหตุนี้ปรากฏว่าสำนักงานประเมินของจำเลยประเมินภาษีโจทก์โดยอาศัย
อัตรากำไรสุทธิของนิติบุคคลอื่นมาเป็นเกณฑ์เทียบเคียงในการคำนวณกำไรสุทธิของ
โจทก์ โดยไม่ใช้อำนาจประเมินตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น ศาล
ฎีกาจึงวินิจฉัยว่าเป็นวิธีการประเมินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นที่สังเกตว่าประมวล
รัษฎากรกำหนดให้สำนักงานประเมินมีอำนาจประเมินภาษีอากรโดยอาศัยเทียบ
เคียงรายได้หรือฐานะของบุคคลอื่นได้ก็เฉพาะแต่การประเมินภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ซึ่งบัญญัติไว้เป็นพิเศษในมาตรา 49 มิใช่เป็นหลักทั่วไปในหมวด 2 ส่วน 1
จึงหาอาจนำไปใช้ในการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ไม่ ผู้บันทึกเห็นว่า ผู้ใช้
ประมวลรัษฎากรจำเป็นต้องพิจารณาให้ลึกซึ้งเข้าถึงซึ่งหลักนิติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกัน
อย่างเป็นระบบมิฉะนั้นจะสับสน ทั้งต้องตีความโดยเคร่งครัดเพราะประมวลรัษฎากร
มีลักษณะเป็นกฎหมายมหาชน หาอาจตีความขยายโดยไม่มีหลักเกณฑ์ได้ไม่
วัชรินทร์ปัจเจกวิญญูสกุล